

0002604-31.2018.8.26.0477

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO MARTINS DAS NEVES

Vistos.

Alexsandro Martins das Neves está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 03 de março de 2018, às 22h50min, na Rua Brasil para Cristo, Mirim, nesta cidade e Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo nº 0002604-31.2018.8.26.0477 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002604-31.2018.8.26.0477 - Nº de Controle 2018/000703

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXSANDRO MARTINS DAS NEVES

Vistos.

Alexsandro Martins das Neves está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 03 de março de 2018, às 22h50min, na Rua Brasil para Cristo, Mirim, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, guardava e trazia consigo, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes em 3 eppendorfs de cocaína e 4 porções de maconha, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 22 de março de 2018 (fls. 86/91).

O réu foi citado por edital (fls. 131), suspendendo-se o processo e o curso do prazo prescricional em 17 de dezembro de 2018 (fls. 134). Posteriormente, o réu foi citado pessoalmente (fls. 159), apresentando resposta à acusação às fls. 164/168,

contudo, foi ratificado o recebimento da denúncia e revogada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, decisório este datado de 11 de junho de 2019.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas; ao final, o réu foi interrogado. Os debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público ofertou seus memoriais às fls. 218/224 e requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou em suas alegações finais acostadas às fls. 231/246, pelo reconhecimento da nulidade processual em razão da busca ilícita efetuada, com a consequente absolvição do acusado. No mérito, bateu pela fixação da pena-base no mínimo legal, a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, o estabelecimento de regime diverso do fechado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

Ouvido em juízo, o guarda civil municipal Edmilson Gomes da Silva Júnior não se recordou da ocorrência, ratificando seu depoimento prestado em solo policial.

A testemunha Maykon Gonçalves Zwarg, guarda civil municipal, disse que estava em patrulhamento pelo bairro quando avistou o acusado saindo de um beco, o qual, ao notar a guarnição, colocou algo em sua boca, razão pela qual foi abordado e localizado os entorpecentes em sua boca e na jaqueta. Na delegacia, o acusado confessou a mercancia ilícita.

Interrogado em juízo, o acusado confessou os fatos.

Pois bem, verifica-se dos autos que guardas civis metropolitanos estavam em patrulhamento quando avistaram o réu, o qual teria demonstrado nervosismo e caminhado com mais rapidez, razão pela qual foi abordado, conforme se observa dos depoimentos prestados em solo policial (fls. 5/6), sendo então localizado três eppendorfs em seu bolso e, por estar com dificuldade para falar, pediram para que abrisse a boca, oportunidade em que foi constatado quatro porções de ervas embaladas em plástico transparente, e o acusado foi detido em flagrante pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante da mecânica dos fatos, patente a ilicitude da prova da materialidade do delito e, consequentemente, da autoria dos eventuais atos penalmente ilícitos.

Como se sabe, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 144, parágrafo 8º, atribuiu às guardas municipais a tarefa de proteção aos bens, serviços e instalações do Município, não as fazendo, pois, auxiliares da Polícia Militar e nem lhes conferiu função repressiva dos crimes, e, dessa forma, as guardas municipais só podem existir se destinadas à proteção dos bens, serviços e instalações do Município, não lhes cabendo, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais (TJ/SP - Apelação Criminal n. 288.556-3 - Indaiatuba - 7ª Câmara Criminal - Rel. Des.: Celso Limongi - j. 22.02.00; TJ/SP); aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas pela Constituição Federal às polícias militar e civil. Dessa forma, "guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressão previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do § 8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares. A auxiliar na compreensão e interpretação desse texto legal, insta realçar o ensinamento do Professor José Afonso da Silva no sentido de que a segurança pública constitui atividade de competência e responsabilidade exclusiva de cada unidade da Federação, de acordo com o disposto no artigo 144, §§ 4º, 5º e 6º. Acerca da competência das guardas municipais, esclarece o autor: "Os constituintes recusaram várias propostas no

sentido de instituir alguma forma de polícia municipal. Com isso, os Municípios não ficaram com nenhuma específica responsabilidade pela segurança pública. Ficaram com a responsabilidade por ela na medida em que sendo entidade estatal não pode eximir-se de ajudar os estados no cumprimento dessa função. Contudo, não se lhes autorizou a instituição de órgão policial de segurança e menos ainda de polícia judiciária. A Constituição apenas lhes reconheceu a faculdade de constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Aí certamente esta uma área que é de segurança pública: assegurar a incolumidade do patrimônio municipal que envolve bens de uso comum do povo, bem de uso especial e bens patrimoniais" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000022-23.2014.8.26.0631, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Márcio Bartoli, j. 09/05/16).

Nem se alegue a edição da Lei nº 13.022/14 para justificar e legitimar os atos supra mencionados, pois tal ato legislativo foi editado para regulamentar o artigo 144, parágrafo 8º, da Constituição Federal e, assim, como se sabe, por se tratar de regra hermenêutica constitucional elementar, as normas infraconstitucionais regulamentares não podem alargar o âmbito de competências estipuladas pela norma constitucional, que não concedeu à guarda municipal qualquer atuação em matéria de segurança pública, razão pela qual, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da legalidade, só podem atuar aonde a lei autoriza.

Daí que a falta de previsão constitucional implica verdadeira vedação de agir na esfera de serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais (TJ/SP - Apelação Criminal nº 0007989-92.2015.8.26.0564, 1ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Márcio Bartoli, j. 29.02.16); portanto, "de fato, a busca e apreensão de entorpecentes não está entre as funções delegadas à guarda municipal pela Carta Magna (artigo 144, § 8º, da Constituição Federal)". (TJSP. 16ª Câmara Criminal. HC nº 2016545-19.2020.8,26.0000. Rel. Otávio de Almeida Toledo. j. 04/08/20).

Inegável, pois, que os guardas civis metropolitanos não tinham - e não têm ! - competência legal e não estavam investidos de autoridade para efetuar a abordagem e a revista pessoal no réu e, conseqüentemente, fazer a apreensão das drogas (TJ/SP - Apelação Criminal n. 290.558-3 - Piracicaba - 7ª Câmara Criminal - Relator: Gomes de Amorim - 12.01.00 - V.U.), inclusive porque sequer testemunharam atos criminosos sendo praticados, mas, apenas, estavam em patrulhamento, quando, então, "suspeitaram" do acusado e não tinham identificado a posse de qualquer objeto ilícito em um primeiro momento, exercendo, pois, verdadeira atividade de polícia judiciária ao realizarem busca pessoal decorrente de atitude suspeita do acusado. Por outro lado, nem se alegue que em decorrência do poder de prender qualquer um em estado de flagrância, nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, estaria a guarda municipal ou qualquer cidadão autorizado a efetuar buscas pessoais e apreensões, por se tratarem de coisas absolutamente diversas.

Uma coisa é a prisão em flagrante - disciplinada pelos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal - que pode ser realizada por qualquer do povo. Outra a busca (pessoal) e apreensão - disciplinada pelos artigos 240 a 250 do referido codex - que somente pode ser realizada por autoridade pública devidamente competente para o ato (v. PITOMBO, Cleunice Bastos, Da Busca e Apreensão no Processo Penal, 2ª ed., São Paulo: Ed. RT, p. 183 e sgts.).

Na verdade, a questão foi invertida, pois não houve a prisão em flagrante e depois a busca pessoal com a apreensão das drogas; ao contrário, primeiro houve a revista pessoal e apreensão das drogas e, posteriormente, a prisão em flagrante, inclusive porque os guardas foram categóricos ao afirmarem que suspeitaram devido ao "nervosismo" demonstrado, ou seja, não testemunharam a prática de crime ou perseguiam o réu em razão de prática de ilícito, mas desconfiaram do réu e, em razão de tal desconfiança, houve a busca pessoal com apreensão das drogas, o que, então, gerou a prisão em flagrante do acusado. Se não havia flagrante evidente, não poderiam mesmo atuar, uma vez que a GCM não integra a estrutura de segurança pública constitucionalmente prevista, então, embora qualquer do povo possa efetuar uma prisão em flagrante, e por isso igualmente admite-se tal possibilidade aos guardas civis municipais, por outro lado só se pode admitir a legalidade da conduta

quando a flagrância se dá de pronto, o que não ocorreu no caso dos autos, eis que a abordagem se pautou em mera suspeita. Nesse sentido:

"A dinâmica dos fatos aqui tratados evidencia que a conduta dos guardas municipais atuantes no caso não restou amparada pelo artigo 301 do Código de Processo Penal. Afinal, a prisão do ora apelante não decorreu de situação flagrancial presenciada pelos agentes públicos no desempenho de sua atuação ordinária. Pelo contrário, como visto, ao depararem com o acusado na via pública, os sentinelas não tinham conhecimento do que havia no interior da sacola que ele mexia, sendo certo que a descoberta de entorpecente resultou de posterior exame, após terem abordado Victor Gabriel. A atividade averiguatória levada a efeito pelos servidores públicos, por certo, conflitou com o papel constitucional da Guarda Municipal, tarefa primordialmente voltada à segurança patrimonial. Como cediço, segundo o artigo 144, § 8º, da Lei Maior, incumbe-lhe a função de proteção dos bens, serviços e instalações municipais." (TJSP - Apelação Criminal nº 1502912-39.2020.8.26.0536 - 5ª Câmara Criminal - Rel. Des. Geraldo Wohlers. j. 12/04/21);

"Prova criminal ilícita. Ocorrência. Apreensão de crack. Busca pessoal realizada por guardas municipais. Exorbitância da esfera de competência. Inteligência do art. 144, §8º, da cf. Apreensão nula. Comprometimento da certeza da materialidade da infração. Absolvição mantida. Recurso não provido. Realizada por quem não tem competência legal, a busca resulta em apreensão nula, que não serve para provar posse de droga e compromete a certeza da própria materialidade da infração" (TJ/SP - Apelação nº 198.513/3, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Dante Busana, j. 07/03/1996);

"Revisão Criminal. Roubo qualificado. Abordagem do réu por Guardas Municipais. Existência de prova a contaminar a ação penal. Impossibilidade de realização pela Guarda Municipal de atos privativos das Polícias Judiciária e Militar. Pretensão absolutória acolhida Apelo provido" (TJ/SP - Revisão Criminal nº 0162917-15.2013.8.26.0000, 1º Grupo de Direito Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 04/04/14);

"TÓXICO - Uso próprio - Apreensão da droga resultante de busca pessoal realizada por guarda civil municipal, sem competência para tanto - Artigo 144, § 8º , da Constituição da República - Ineficácia - Absolvição decretada - Recurso não provido" (JTJ 184/312);

"PROCESSO-CRIME - Nulidade - Ocorrência - Guardas Municipais que ingressaram no domicílio dos Apelantes de madrugada, procederam à revista e apreenderam entorpecente e armas, sem ordem judicial - Falta de poder de polícia para tal ato - Artigo 144 da Constituição Federal que outorgou exercício da segurança pública à Polícia Civil e Militar - Guarda Municipal destinada tão-só à proteção dos bens, serviços e instalação do Município, conforme dispuser a lei - Coação ilegal existente - Habeas Corpus concedido de ofício nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal. Guarda Municipal é guarda de patrimônio público municipal e não está investida de funções de natureza policial e dar busca pessoal em quem quer que seja" (TJ/SP - Apelação Criminal n. 269.826-3 - 4ª Câmara Criminal - Rel. Des. Bittencourt Rodrigues - j. 24.08.99);

"TÓXICO - uso próprio - Absolvição - Necessidade - Droga apreendida por guarda municipal - Apreensão realizada sem a presença de testemunhas - Propriedade negada pelo acusado - Guarda municipal, ademais, que não é investido de autoridade para a realização de busca pessoal - Recurso provido" (TJ/SP - Apelação Criminal nº 290.558-3 - Piracicaba - 7ª Câmara Criminal - Rel. Des. Gomes de Amorim - j. 12.01.00);

"A admissão de investigação criminal por órgãos outros, v.g. guarda municipal, implica grave subversão da previsão constitucional (com inegáveis prejuízos à

eficiência da persecução), em prejuízo das liberdades individuais, com o agigantamento estatal, que tem seu poder de punir cada vez mais ampliado e livre de amarras, ao passo que o indivíduo sequer tem mais referência e previsão dos agentes estatais com legitimidade e idoneidade para a apuração de um suposto ilícito criminal (com todas as consequências e implicações notoriamente insitas). Guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressa previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do § 8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares" (Revisão Criminal nº 0054130-81.2016.8.26.0000, Comarca de Indaiatuba, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais. Rel. Des. Márcio Bartoli, j. 05/02/2018).

Dessa forma, patente que a própria prisão em flagrante estava nula, já que decorrente de diligência ilegal, qual seja, a busca pessoal no acusado por autoridade incompetente, inclusive porque a prova obtida por meio de revista pessoal realizada por guarda municipal é ilegítima, por ausência de autorização legal, contaminando tudo que dela derivou (TACRIM/SP – Apelação Criminal nº 1.270.983-9 – 4ª Câmara Criminal – rel. Des. Marco Nahum – j. 18.09.2001; TJ/SP – Apelação Criminal nº 938.307.3/7; TJ/SP – Apelação Criminal nº 1.070.364.3/0). Ademais, não custa ressaltar que o "excesso de função" praticado pela guarda municipal não se justifica mesmo com a apreensão das drogas, pois "a ilegalidade do ato praticado, além de eticamente inadmissível, não se transmuda em ato lícito, ainda que em detrimento da apuração da verdade, porque ofende um direito fundamental da pessoa humana, valor que, proporcionalmente, se sobrepõe ao interesse da sociedade no combate ao crime. "É um pequeno preço que se paga por viver-se em Estado Democrático de Direito" (ALEXANDRE DE MORAES, Direito Constitucional, 4ª edição, revista e ampliada, São Paulo: Editora Atlas S.A., 1998, p. 110)" (TACRIM/SP – Apelação Criminal nº 1.270.983-9 – Santos – 4ª Câmara Criminal – rel. Marco Nahum – j. 18.09.2001).

Dessa forma, ante o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal realizada no acusado e da apreensão das drogas, com a conseqüente contaminação da própria prisão em flagrante, outra alternativa não resta a não ser a absolvição.

Ante o exposto, absolvo o réu Alexsandro Martins das Neves da imputação que lhe é feita nos presente autos, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. Não obstante a solução, à vista da inafastável ilicitude das drogas apreendidas, com o trânsito da presente destruam-se os entorpecentes. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Custas processuais na forma da lei.

P.I.C.

Praia Grande, 4 de outubro de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA